

1500432-62.2022.8.26.0619

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Requereu, ainda, o afastamento do tráfico privilegiado, com a aplicação do regime inicial fechado.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela aplicação da pena no patamar mínimo, com o reconhecimento do tráfico privilegiado. Requereu, ainda, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, com a fixação do regime aberto. É o relatório.

Fundamento e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

1ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, ., Centro - CEP 15900-000, Fone: (16) 3252-5533,

Taquaritinga-SP - E-mail: taquaritinga1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500432-62.2022.8.26.0619

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLLEY DE BARROS MELO

Data da Audiência:

21/09/2022

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Aos 21 de setembro de 2022, às 14:00h, na sala virtual de audiências do aplicativo Microsoft Teams da 1ª Vara, da Comarca de Taquaritinga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, com supedâneo no Provimento CSM nº 2651/2022. Foi feito uso da ferramenta Microsoft Teams, estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais. Todos os participantes desta audiência o fizeram em tempo real, pois é assim que funciona a própria plataforma digital. Pavia e separadamente, reuniram-se o acusado e seu defensor por meio de reunião paralela, no próprio Teams. Após, instalou-se formalmente a audiência. Verificou-se a presença do DD. Representante do Ministério Público o DR. PAULO AUGUSTO RADUNZ JUNIOR. Presente o réu WESLLEY DE BARROS MELO e seu Defensor o DR. GUSTAVO AUGUSTO DE CARVALHO-OAB 194209/SP. Presentes as testemunhas FAGNER CESAR MOREIRA e IVAN ANDRÉ SCAVONI. Iniciados

os trabalhos, foram colhidos os depoimentos das testemunhas FAGNER CESAR MOREIRA e IVAN ANDRÉ SCAVONI e o interrogatório do réu, pelo sistema audiovisual. Os depoimentos das testemunhas foram tomados sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no art. 210, do Código de Processo Penal. O interrogatório do acusado está em conformidade com o artigo 405, § 1º, do CPP. A gravação da audiência ficará armazenada no sistema informatizado SAJ-PG5. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Então não havendo outras provas a serem produzidas, nem requerimento de diligências pelas partes (artigo 402 do Código de Processo Penal), o MM. Juiz encerrou a instrução. Na sequência, foi dada a palavra ao DD. Promotor de Justiça e à Defesa, para alegações finais orais, as quais foram colhidas pelo sistema audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida a sentença:

"Vistos.

WESLEY DE BARROS MELO, qualificado nos autos, está sendo processado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 04 de abril de 2022, por volta das 11:30 horas, no cruzamento das ruas Francisco Cantunário, com José Restani, no Jardim Maria Luiza, nesta cidade e Comarca de Taquaritinga, trazia consigo 10 (dez) eppendorfs contendo "cocaína", pesando 13 gramas, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 17) e laudo pericial (fls. 70/72), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02).

Em audiência de custódia foi concedido ao acusado o benefício da liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares (fls. 42/46).

Deferida a quebra de sigilo dos dados telefônicos (fls. 67/68).

O Ministério Público requereu a prisão preventiva do acusado (fls. 125/126), a qual foi deferida em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas (fls. 135/136).

O réu foi notificado (fls. 229) e apresentou defesa prévia (fls. 214).

A Denúncia foi recebida em 02 de setembro de 2022 (fls. 216/217).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento pelo sistema de videoconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. Requereu, ainda, o afastamento do tráfico privilegiado, com a aplicação do regime inicial fechado.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela aplicação da pena no patamar mínimo, com o reconhecimento do tráfico privilegiado. Requereu, ainda, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, com a fixação do regime aberto. É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido da ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), fotografias (fls. 13/16), laudo de constatação preliminar de entorpecente (fls. 17), laudos periciais (fls. 70/72 e 85/87), auto de materialização de evidência eletrônica (fls. 88/113) e pela prova oral produzidas nos autos.

A autoria também é incontestada.

Em solo policial, o acusado declarou que até a semana anterior ao flagrante trabalhava na empresa Brumau, "puxando" palha de amendoim. Afirmou que estava em frente ao "Mercado do Leo", do lado de fora, fumando um "paieiro", quando viu que se aproximava uma viatura da Polícia Militar. Disse que os policiais militares pararam, desceram da viatura e o abordaram. Foi submetido a busca pessoal e nada de ilícito foi localizado consigo. Anotou que tinha apenas R\$ 70,00 em dinheiro, que seu pai havia lhe dado para consertar a motocicleta dele e um telefone celular, sem chip, pertencente ao seu irmão. Afirmou que permaneceu sentado em cima de suas mãos

enquanto que os policiais saíram e depois voltaram, dizendo que tinham encontrado pinos de "cocaína" e que tais drogas eram suas. Negou que as drogas fossem suas e alegou que os policiais "plantaram" essas drogas para incriminá-lo. Contou que dias antes, estava do lado de fora do "Bar da Jaque", quando viu que policiais militares estiveram no local, revistaram o local e também as imediações e depois foram embora. Acredita que foi abordado na data dos fatos em razão disso, mas não portava droga alguma. Negou que seja traficante ou usuário de drogas.

Em juízo, o réu confessou os fatos que lhe foram imputados. Declarou que praticou o tráfico, pois sua família estava passando necessidades, precisando de dinheiro. Afirmou que vendeu drogas em cinco ou seis dias somente. Alegou que não tem whatsapp e que o celular apreendido pertence ao seu irmão, de 10 anos de idade. Esclareceu que as mensagens foram extraídas do "messenger" do Facebook. Afirmou que vendeu a droga por uns 05 ou 06 dias, separadamente. Alegou que é usuário de maconha. Anotou que teve uma passagem quando menor, mas não foi internado. Contou que já foi abordado em outras vezes pelos policiais. Alegou que antes dos fatos estava trabalhando.

A confissão do acusado restou corroborada pelas demais provas colhidas sobre o crivo do contraditório.

A testemunha Fagner César Moreira, policial militar, declarou que na data dos fatos realizavam patrulhamento de rotina pelo Bairro Maria Luiza, com vistas a um local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram Wesley, que saiu andando. Afirmou que o réu tentou empreender do local. Afirmou que desembarcaram para a realização da abordagem, momento em que o réu soltou vários pinos de "cocaína", que estavam em suas mãos e saiu correndo. Asseverou que alcançaram Wesley, que foi abordado e revistado, sendo encontrado com Wesley a quantia de R\$ 76,70 em dinheiro e um telefone celular. Retornaram até o local onde o acusado havia dispensado os pinos de "cocaína" e os recolheram. Explicou que as drogas estavam todas embaladas em 10 microtubos, individualizadas e prontas para a venda. Informou que o acusado, corriqueiramente, é abordado naquela região do bairro e quase sempre possui valores em dinheiro, mas até então não haviam sido encontradas droga com ele. Afirmou que, convicto de que Wesley estava realizando o tráfico de drogas naquele local, dera voz de prisão a ele. Esclareceu que já abordou o acusado em outra ocasião, porém, não se recorda de ter localizado algo de ilícito na posse dele.

A testemunha Ivan André Scavoni, policial militar, declarou que na data dos fatos ele e seu colega Cabo PM Fagner, patrulhavam pelo bairro Jardim Maria Luiza, quando avistaram o acusado na esquina das ruas Francisco Cantuário com José Restani, local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao perceber a viatura policial, Wesley saiu andando tentando deixar o local. Informou que partiram para a abordagem, contudo, naquele momento Wesley soltou ao chão vários pinos de "cocaína", que estavam nas mãos dele e saiu correndo. Alegou que o alcançaram e que abordado e revistado, encontraram com ele a quantia de R\$ 76,70 em dinheiro e um telefone celular. Retornaram até o local onde Wesley havia dispensado os pinos de "cocaína" e os recolheram, totalizando 10 unidades, embaladas e prontas para venda.

A prova é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta para ensejar a condenação do acusado.

Os depoimentos dos policiais foram seguros ao indicar que o réu trazia consigo droga para fins de venda.

Não há que se falar em valor reduzido dos depoimentos dos policiais. Nada há nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar falsamente o réu e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade.

Veja-se, à propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas

que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello). "Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (STJ - HC n. 449.657/SP, Min FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 14/8/2018).

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROVIMENTO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os policiais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminar o acusado falsamente, impõem-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Recurso provido, para condenar o apelado pelo delito do artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/06. (TJSP. Apelação Criminal 1500057-52.2020.8.26.0580; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 25/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021) - grifei. Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo 13 porções de cocaína (2,66 gramas) – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJSP. Apelação Criminal 0000581-23.2016.8.26.0594; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020) - grifei. Narraram com detalhes a dinâmica dos fatos. Não há contradição, os depoimentos são uníssonos.

Em verdade, seria um contrassenso exigir o exercício da ação inibidora da polícia para combater as infrações penais e, quando ela tem sucesso nessa empreitada, dizer que seu depoimento é inválido, suspeito, mentiroso, parcial, por que não dizer, criminoso.

Não bastasse, o acusado confessou em juízo os fatos narrados pelos policiais e confirmou que a droga apreendida se destinava ao comércio.

Além disso, durante a abordagem, na posse do réu, foi apreendido um aparelho celular e, realizada perícia, foi elaborado o laudo de materialização de evidência eletrônica (fls. 88/113), cujo conteúdo das conversas extraídas confirma o envolvimento do réu com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Neste contexto, destaco alguns excertos de diálogos, em que o acusado refere possuir drogas para venda e ainda, estar trabalhando na "lojinha" ou na "biqueira": Em conversa com pessoa identificada como Vitor Gabriel, Wesley afirma "aqui tem", "maconha tô sozinho na bocada"; "tem parada aqui" (sic - fls. 90).

Em diálogo travado com pessoa identificada como Lara Oliveira, o réu afirma "AE os b,o tá no armarinho" (sic - fl. 91).

Em outros diálogos, travados entre Wesley e Biah Lima, em diversas ocasiões, o réu afirma que "está na loja" (fls. 105/106/107) e ainda que "hj os cara em quadro já dentro do bar", "já passou duas veis", "os cara acho 6 pino não era nem nosso", "mais os cara já sabe q é eu q tô os cara já até me conheceu" (sic - fl. 107/108).

Ainda, em conversa com pessoa identificada com Hiago Reis, este questiona se o réu estaria na "biqueira", dizendo que irá "encostar aí buscar um verde" (fls. 112).

Ademais, do conteúdo extraído da pasta de imagens do celular apreendido em poder réu há fotografia de valores em dinheiro e drogas, expostas em uma mesa de bilhar fls. 112/113.

Assim, diante do teor dos diálogos em destaque, não há dúvidas de que o réu faz do tráfico meio de vida, dedicando-se crime. Não se trata de tráfico eventual. Reforce-se ainda, que foi encontrada em poder do réu a quantia de R\$ 76,70 (setenta e seis reais e setenta centavos), em notas diversas, sem que tenha comprovado o exercício de qualquer atividade lícita, destacando-se o fato de ter se autodeclarado desempregado, quando da sua qualificação em solo policial (fls. 28). Por fim, registro que a quantidade de droga apreendida (10 microtubos de cocaína) e a forma como estava embalada, autoriza a considerar que a substância entorpecente era destinada ao consumo de terceiros, sendo tal preceito expresso na Lei nº 11.343/06.

Cumpra anotar, que em razão do crime de tráfico de drogas constituir atividade clandestina, não é necessário, para a sua caracterização, o flagrante da comercialização das substâncias ilícitas para que se conclua pela autoria do crime em tela, sendo suficiente para tanto a análise das circunstâncias e indícios que conduzem a incriminação, todos a respaldar a convicção pela autoria do acusado no crime de tráfico de drogas.

À propósito, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória. (STJ - REsp 1361484/MG Rel. Min. Rogério Schietti Cruz Sexta Turma j. 10/06/2014).

No mesmo sentido:

Tráfico de Entorpecentes - Art. 33, Lei 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Pena base reduzida.

Substituição da pena. Incabível - Requisitos dos benefícios não foram satisfeitos. Regime mantido. Recurso parcialmente provido. (TJSP. Apelação Criminal 0016290-94.2017.8.26.0196; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019) - grifei.

Ademais, é cediço que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra.

O uso de entorpecente é a porta de entrada para a atividade de traficância. Assim, incabível o pleito desclassificatório, pois as drogas que possuía não eram destinadas ao uso. Neste sentido: "A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido pequena quantidade do tóxico em poder do réu" (STF 1ª T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768).

Portanto, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Nesta senda, a prova coligida é segura e eficaz para justificar a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo e culpabilidade do agente, sendo a condenação de rigor.

Passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, a pena base será fixada em 1/6 acima do mínimo legal, em razão da natureza do entorpecente apreendido, já que a "cocaína" possui efeitos devastadores.

Com efeito, quando o legislador determinou, no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que o juiz, na fixação das penas, considere com preponderância sobre o previsto no artigo

59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância, quis dizer que, quem trafica "cocaína" deve ser punido mais severamente do que quem trafica outras drogas menos vulnerantes, como, por exemplo, apenas a maconha.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Absolvição - Improcedência - Materialidade e autoria demonstradas - Acusado surpreendido com 14 pinos de cocaína, com peso líquido total de 19,41g - Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais militares - Intuito mercantil demonstrado - Condenação de rigor - Dosimetria - Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo legal - Natureza do entorpecente apreendido que justifica o aumento - Artigo 42 da Lei nº 11.343/06 - Reprimenda agravada em 1/6 pela reincidência - Redutor do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 e Substituição penal - Inaplicabilidade - Requisitos legais não preenchidos - Regime inicial fechado mantido, porque adequado à gravidade concreta da conduta praticada - Recurso não provido (TJSP. Apelação nº 0001327-39.2018.8.26.0619. Relator(a): Salles Abreu. Comarca: Taquaritinga. Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 17/12/2018. Data de publicação: 15/01/2019). Negritei.

Ainda, a esse respeito:

"O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006". (AgRg no HC 631774 / SE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0327617-0. Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/03/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 29/03/2021) - grifei.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA NOCIVA DAS DROGAS APREENDIDAS (CRACK E COCAÍNA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes de tráfico de drogas, o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal - CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) justifica a majoração da pena-base, em relação à Debora, bem ainda a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em seu patamar mínimo, para o réu Geraldo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. Processo" (AgRg no HC 476995 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0289466-0 Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/04/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 03/05/2019) - grifei.

"A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC 687055624 - Rel. Des. Jorge Alberto de Moraes Lacerda, v. un. 29.12.1987).

Pena-base, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e menoridade relativa (fls. 31), de modo que a pena deve retornar ao patamar mínimo, na medida em que nesta fase não é possível a redução aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ). Pena em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena. Deixo de aplicar o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista que, consoante mensagens extraídas pelo laudo de materialização de evidência eletrônica (fls. 88/113), ao menos desde dezembro de 2021 (fls. 112) o réu pratica atos relacionados ao comércio de entorpecentes, indicando que se dedica, com frequência e anterioridade às atividades criminosas, de modo a justificar o afastamento do privilégio.

Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 630, DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONVERSAS VIA WHATSAPP. DEMONSTRAÇÃO DE LÓGISTICA NA VENDA DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA BENESSE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A hipótese na qual o réu assume a posse dos

entorpecentes, mas alega que a destinação era para consumo pessoal não configura confissão espontânea, sendo necessário, para tanto, o reconhecimento do ato de traficância, conforme jurisprudência pacificada na Súmula 630, do STJ.

2. As conversas via WhatsApp acostadas aos autos indicam com clareza que o réu mantinha uma cadeia logística na venda de entorpecentes, com informações sobre preço de aquisição, de fornecedores, inclusive estrangeiros, cálculo de lucros, perdas e ganhos, circunstância que afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado, por demonstrar dedicação à atividade criminosa. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido". (Acórdão 1189069, 20160111136483APR, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: WALDIR LEÔNIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: 137/148).

Assim, torno definitiva a pena 05 (cinco) anos de reclusão.

Fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena (artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal).

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme o art. 77 do mesmo diploma legal.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal que a Justiça Pública move contra WESLEY DE BARROS MELO, qualificado nos autos, e o CONDENO à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Diante da aplicação do regime semiaberto, faculto à ré o direito de recorrer em liberdade.

De acordo com a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, não se admite impor, em sede cautelar, regime mais gravoso à liberdade do acusado do que aquele fixado na sentença penal condenatória, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário" (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017).

"Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção.

Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4.

Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).

No mesmo sentido, manifestou-se a Ministra Carmen Lúcia nos autos do HC 182567, fundamentando que "Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo sequer modulação da custódia cautelar para se adequar

ao regime inicial menos gravoso". (STF, HC 182.567/RJ, j. 18/03/2020).

Deste modo, revogo a prisão preventiva.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei nº 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Transitada em julgado esta sentença: a) destruam-se as amostras de droga guardadas para contraprova (art. 72 da Lei de Drogas); b) expeça-se/adite-se e encaminhe-se guia de recolhimento definitiva; c) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; d) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); e) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF; f) diante da pena de multa cumulativamente aplicada, nos termos do disposto no art. 480 das NSCGJ, alterado pelo Provimento CG Nº 05/2022, expeça-se certidão de sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade que ora defiro.

Expeça-se todo o necessário, fazendo as comunicações de praxe.

Regularizados os autos e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P.I.C."

O dispositivo da r. sentença foi lido pelo magistrado às partes e seu inteiro teor disponibilizado nos autos digitais nesta data. Na sequência, tanto o Defensor quanto o réu interpuseram recurso de apelação, sendo que o Ministério Público concordou com a sentença, não querendo dela recorrer. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Dou por certificado nesta data o trânsito em julgado para o Ministério Público. Recebo o recurso interposto, saindo o defensor intimado que o prazo para apresentação das razões recursais se inicia na data de amanhã. Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público para contrarrazões de recurso (CPP, art. 600). Após, observadas as cautelas de praxe, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Seção Criminal, com as nossas homenagens aos seus ilustres integrantes. Encaminhe-se as gravações da audiência realizada, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020." Saem os presentes intimados. Publicada em Audiência, nos termos do Comunicado CG Nº 2200/2016. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação de audiovisual em audiência, as ocorrências, manifestações e declarações e depoimentos captados em vídeo, foram disponibilizados no website do Tribunal de Justiça de São Paulo. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Luana Yuri de Araújo, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA